

更没有逃脱监管的意图，更多的是无心之举，与《中华人民共和国社区矫正法 实施办法》第三十五条第一项至第五项故意为之的情形显然不同，不能简单认定为“情节严重”，与前四项应当给予警告的情形相比不具有相当性。所以社区矫正机构作出的警告不合法、不合理，不能成立。

2. 撤销缓刑案件“情节严重”的审查标准。根据《中华人民共和国刑法》第七十七条规定，撤销缓刑条件：一是绝对撤销缓刑，即在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决；二是相对撤销缓刑，即在缓刑考验期限内违反相关规定或者禁止令，情节严重。撤销缓刑的情形表现为该罪犯主观上没有真正悔改，客观上仍然对社会有危害，不能相信其能够自主地纠正自身行为偏差，缓刑理由已不复存在，有必要执行原判刑罚，予以惩戒。针对上述相对撤销缓刑情形，即违反规定或者禁止令属于客观标准要件，情节严重属于主观裁量要件。故关于撤销缓刑案件“情节严重”的审查标准，可以从以下角度考量：

(1) 遵循罪责刑相适应原则。根据《中华人民共和国刑法》第五条的规定，刑罚的轻重，应当与犯罪分子所犯罪行和承担的刑事责任相适应，变更刑罚执行方式是直接改变原案裁判结果，将非监禁刑罚变更为监禁刑罚。针对这种情形，必须严格遵循罪责刑相适应原则，才能确保该原则落到实处，严格审查缓刑犯违法严重性、社会危害性是否足以达到适用监禁刑罚执行标准，不可任意扩大适用范围。结合客观事实和主观认知，准确认定是否属于“情节严重”应予撤销缓刑的情形。另外，缓刑犯在缓刑考验期间需要遵守的相关规定难

以穷尽，以及何时正式开始计算缓刑考验期间，这些都需要社区矫正机构在 缓刑考验期间开始时进行充分告知，以便认定缓刑犯是否存在主观故意。

(2) 坚持政治效果、法律效果和社会效果有机统一。缓刑制度体现了人民法院与群众路线相结合的司法治理路线，即缓刑由人民法院宣告、执行由社区矫正机构负责，以实现社区矫正“三个效果”。同时，变更刑罚执行制度是为了体现国家法律和司法裁判的权威，惩戒和震慑违法犯罪，保证缓刑犯刑罚执行工作有序推进，充分保障缓刑犯合法权益，综合考虑缓刑犯人身危险性、违

法行为严重程度、已投入执行成本和社会效果等因素，体现了宽严相济刑事政策。行为人若非具有较大人身危险性，以及不羁押不足以惩戒罪犯情形，一般不宜对其撤销缓刑。若撤销缓刑后行为人将要承担更重刑罚，社会秩序将受到更大影响，人民法院应当更加审慎作出判断，发挥好非监禁刑罚教育矫治功能，提升缓刑犯自我身份认同和社会认同感，让罪犯有机会改过、有出路自新，提升犯罪治理效能。

编写人：广东省广州市荔湾区人民法院 余友斌 何涵吟

直系亲属主动上缴爆炸物应作为 对被告人量刑和适用缓刑的酌定从轻情节

—— 肖某某非法储存爆炸物案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

湖南省湘西土家族苗族自治州中级人民法院(2023)湘31刑终180号刑事判决书

2. 案由：非法储存爆炸物罪

【基本案情】

2013年下半年，被告人肖某某在某矿区做事时，发现矿洞内有剩余的炸药和导火索，便将其带回位于某村的家中(以便将来用于给庄稼施肥)，并用塑料袋包裹好存放于三楼房间，后外出务工。2022年10月，肖某某的次子肖某在家中打扫卫生时，发现上述炸药和导火索，遂将其上交至民乐派出所，并告知肖某某。经称重、测量，炸药总重量为5.6922公斤，导火索总长度为2.78

米。后经检测，送检的炸药具备爆炸性。2023年3月1日，经公安机关电话通知，肖某某主动到民乐派出所接受调查。

【案件焦点】

1. 对肖某某应该如何量刑；
2. 对肖某某应否适用缓刑。

【法院裁判要旨】

湖南省花垣县人民法院经审理认为：肖某某系自首，可以减轻处罚；认罪认罚，可从宽处理。检察机关的量刑建议适当。但肖某某非法储存爆炸物没有合法来源，数量大，且时间长，危害公共安全，社会危害性大，不属于犯罪情节较轻，不符合宣告缓刑的条件。判决：

肖某某犯非法储存爆炸物罪，判处有期徒刑三年。

一审宣判后，肖某某上诉提出：肖某某储存的炸药并未造成严重后果；其犯罪情节较轻，主观恶性较小，认罪悔罪态度良好，其储存爆炸物是为了用于施肥，而非用于非法活动。请求改判肖某某适用缓刑。

湖南省湘西土家族苗族自治州中级人民法院经审理认为：肖某某虽然储存爆炸物数量大，达到情节严重的标准，但其初始的目的是施肥，其将炸药放至家中近十年一直未使用，可以排除其非法使用炸药的意图，存放期间也未造成任何社会危害；特别是其儿子发现炸药后主动上交给公安机关并告知其之后，肖某某主动到公安机关投案，该行为与其本人主动上交所起的作用相当。肖某某系自首，可减轻处罚；认罪认罚，可从轻处罚。花垣县司法局经社区矫正评估，建议对其适用社区矫正。肖某某犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。综合其犯罪事实、情节及社会危害性，对其适用缓刑将取得更好的法律效果和社会效果。该院经审委会研究决定，于2023年10月18日作出判决：

一、撤销原判；

二、肖某某犯非法储存爆炸物罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年。

【法官后语】

被告人肖某某储存的炸药数量，根据《最高人民法院关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条的规定，可以认定为属于《中华人民共和国刑法》第一百二十五条第一款所指的“情节严重”。因为肖某某有一处可减轻处罚、两处可从轻处罚的法定情节，二审最后对肖某某只判刑三年，应该认为符合《中华人民共和国刑法》的规定，体现了宽严相济刑事政策。对此，应该充分肯定。

对于肖某某能否适用缓刑，是一审、二审法院分歧所在。应该说，一审法院认为不符合宣告缓刑的条件，是对罪刑法定和罪责刑相适应原则的过于机械的理解和适用，未能充分体现宽严相济刑事政策。

一、确定是否适用缓刑要综合考虑量刑应该遵循的四项指导原则及宽严相济刑事政策

确定是否适用缓刑，当然要遵循罪刑法定、罪责刑相适应等刑法基本原则以及《中华人民共和国刑法》第七十二条等规定及相关司法解释。

二、要将直系亲属主动上缴爆炸物作为对被告人量刑的酌定从轻情节

直系亲属主动上缴违禁品，客观上等于举报被告人有违法犯罪行为。过去司法实践中对此主要是从是否构成自首角度来分析，忽略从是否适用缓刑角度来讨论。

我国古代有两项看似对立、实则统一的重要制度，一是“亲亲相隐”制度，二是十恶不赦制度。前者要求要出于人性中最真挚的情感，对自己的亲人有所袒护、隐瞒，不告发、不作证亲人的罪行；亲属有罪相隐瞒，不论罪或减刑；控告应相隐瞒的亲属，要处刑。后者要求有两类罪（谋反、谋大逆、谋叛及其他某些重罪；某些亲属相互侵害罪）不适用“亲亲相隐”制度。对于直系亲属举报被告人有违法犯罪行为的处理，目前当然应该首先依据，至少不违反刑法、司法解释规定，但适当借鉴我国上述两项制度体现的古代司法智慧，也更有利于体现宽严相济刑事政策。本案系肖某某的儿子肖某主动上缴爆炸物所致。肖某将父亲藏匿的炸药及导火索直接送到派出所，不能认为其主观上就是

想让父亲因此坐牢服刑，其当时认为爆炸物不能私自收藏，应该上缴公安机关，因此其目的应该理解为消除危险。对肖某的这种行为，应该在量刑及适用缓刑方面有所鼓励。辩护律师在一审中提出的肖某某存储的爆炸物系由其儿子主动上交公安派出所的辩护意见，实际上就是基于这方面考虑。二审改判适用缓刑。

综上，确定是否适用缓刑不仅考虑《中华人民共和国刑法》第七十二条等法律规定，也要将直系亲属直接或者间接举报被告人有违法犯罪行为作为对被告人量刑的酌定从轻情节。

编写人：湖南省湘西土家族苗族自治州中级人民法院 王平 胡基厚

社区矫正机构对被告人作出 调查评估否定性意见情况下慎用缓刑

—— 余某某危险驾驶案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

广西壮族自治区柳州市中级人民法院(2023)桂02刑终194号刑事裁定书

2. 案由：危险驾驶罪

【基本案情】

2022年10月2日22时许，余某某酒后驾驶一辆小型普通客车，行驶至柳州市鱼峰区时被执勤交警查获。交警当场对其进行呼气式酒精测试，结果为154毫克/100毫升，后由医务人员为其提取血样。经某司法鉴定所鉴定，余某

某血液内酒精含量为145.92毫克/100毫升。2022年11月25日，被告人佘某某经公安机关电话联系后主动到案接受调查，并如实供述上述事实。

【案件焦点】

社区矫正机构对被告人作出调查评估，并发表否定性评估意见，此情况下应该慎重适用缓刑。

【法院裁判要旨】

广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民法院经审理认为：余某某醉酒后驾驶机动车在道路上行驶，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一第一款第二项，构成危险驾驶罪。公诉机关的指控成立。余某某案发后主动到公安机关接受调查，归案以后能够如实供述自己的罪行，是自首，且认罪认罚，依法可以从轻处罚。综上所述，广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民法院决定对余某某适用从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民法院予以采纳。鉴于余某某的悔罪表现，鱼峰法院对其不予适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一第一款第二项、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十七条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：

余某某犯危险驾驶罪，判处拘役一个月十五日，并处罚金人民币3000元。

一审宣判后，余某某提出上诉。

广西壮族自治区柳州市中级人民法院经审理认为：余某某醉酒后驾驶机动车在道路上行驶，其行为已构成危险驾驶罪。原判认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，审判程序合法。社区矫正机构根据办案机关的委托，依照法律规定向余某某经常居住地的居民委员会了解相关情况，结合向余某某对自身犯罪行为的认识，综合判断其社会危险性及其社区矫正的执行效果等，最终形成调查评估报告，符合法律规定，并无不当。一审法院根据余某某的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，并考虑到其不具备社区矫正的条件，依法对其不适用缓刑，处理正确，广西壮族自治区柳州市中级人民法院予以确认。原判根据余某某的犯罪事实，结合其系自首，且认罪认罚、悔罪表现等，在法定量刑幅度内予以从轻处罚，并不予适用缓刑，量刑适当，处理正确。余某某提出适用缓刑的上诉意见不成立，人民法院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国

刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项之规定，裁定如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

《中华人民共和国刑法》第七十二条第一款明文规定，对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（1）犯罪情节较轻；（2）有悔罪表现；（3）没有再犯罪的危险；（4）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。该条文明确规定对于犯罪情节较轻的犯罪分子，在满足其他条件的情况下，可以适用缓刑。

如何界定被告人是否属于（2）（3）

（4）的情形，则至为关键。根据《中华人民共和国社区矫正法实施办法》第五条第一项的规定，人民法院对拟判处管制、宣告缓刑、决定暂予监外执行的，可以委托社区矫正机构或者有关社会组织对被告人或者罪犯的社会危险性和对所居住社区的影响，进行调查评估，提出意见，供决定社区矫正时参考。由此可见，社区矫正机构对被告人作出的社会调查评估意见在缓刑适用上具有重要参考作用。可以从以下几方面分析。

1. 社区矫正机构的调查评估意见具有直接性和客观性。根据《中华人民共和国社区矫正法》第十七条第二款的规定，社区矫正执行地为社区矫正对象的居住地。社区矫正对象在多个地方居住的，可以确定经常居住地为执行地。第十八条规定，社区矫正决定机关根据需要，可以委托社区矫正机构或者有关社会组织对被告人或者罪犯的社会危险性和对所居住社区的影响，进行调查评估，提出意见，供决定社区矫正时参考。

居民委员会、村民委员会等组织应当提供必要的协助。经查，余某某及其家人于2021年7月至今居住某小区，因此依照法律规定，该居住小区为其经常居住地。社区矫正机构根据办案机关的委托，依照法律规定向余某某经常居住地的居民委员会了解相关情况，结合余某某对自身犯罪行为的认识，综合判断其社会危险性及社区矫正的执行效果等，最终形成调查评估报告，符合法律规定，并无不当。

2. 社区矫正机构的调查评估意见能客观反映被告人的悔罪表现和对所居住

社区有无重大不良影响。缓刑制度的创设，一方面可以弥补短期自由刑的不足，避免恶性较轻的罪犯在监狱“交叉感染”其他恶习；另一方面对缓刑犯不予关押，使其个人、家庭维持基本生活状态，不受影响，从而有利于改造罪犯，也有利于社会的稳定。从制度层面，则要求被矫正对象遵守法规和履行相应义务，包括配合调查、按时报到、接受监管等。从道德层面，则要求被矫正对象改过自新、严守规矩、控制自身行为，不致再犯罪，不给社区和社会“添乱”。本案中，某司法所在对被告人进行社会调查时候发现，余某某认为在乡村道路上酒驾的危害性不大，并未真正意识到醉酒后驾驶机动车的危害，其只是为了换取缓刑机会而认罪认罚，获得缓刑后将立即申请外出，不太愿意接受其居住所在地的社区监管，足以认定余某某主观上悔罪表现不突出，给社区监管带来困难。

3. 社区矫正机构的否定性调查评估意见与认罪认罚并不冲突。认罪认罚制度是被告人对其刑事违法行为和应遭受何种刑罚、刑罚轻重进行肯定性认可，缓刑是一种刑事执行制度，本身并不是一种刑罚。本案余某某对其醉酒后驾驶机动车在道路上行驶的行为性质以及社会危害后果有了清晰的认知，结合其血液中酒精含量，对公诉机关给其作出的量刑建议拘役一个月十五日，罚金人民币3000元的处罚也表示认可和接受，其具有认罪认罚表现。在此基础上，能否适用缓刑，则需借鉴社区矫正机构所作出的调查评估意见，本案中，社区矫正机构所作出的是关于不宜适用缓刑的否定性意见，故最终对余某某未适用缓刑，合法合理，且不与余某某之前所作认罪认罚相冲突。

编写人：广西壮族自治区柳州市中级人民法院 罗艳梅

广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民法院 谢剑峰

跨越缓刑考验期的连续犯罪应整体认定

——何某虚开增值税专用发票案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

广东省佛山市中级人民法院(2023)粤06刑终308号刑事判决书

2. 案由：虚开增值税专用发票罪

【基本案情】

何某因犯虚开增值税专用发票罪于2016年6月24日被湖北省大冶市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币10万元，缓刑考验期从2016年7月5日起至2020年1月4日止。2019年12月，何某介绍某供应链公司的股东及法定代表人陈某为梁某在无实际交易的情况下虚开增值税专用发票并收取手续费。2019年12月16日至2020年2月25日，某供应链公司为梁某虚开增值税专用发票14份，税额合计152852.38元。其中，在2019年12月16日至2020年1月4日虚开增值税专用发票2份，税额合计15075.39元。国家税务总局佛山市税务局稽查局于2022年2月25日作出处罚决定，某供应链公司于2022年3月2日退缴违法所得68816.4元，并缴纳罚款30万元。2022年7月11日，何某主动到公安机关投案。

【案件焦点】

1. 跨越缓刑考验期的连续犯罪应否整体评价；2. 在缓刑考验期内虚开增值税专用发票金额尚未达到犯罪数额标准，能否认定在缓刑考验期内犯新罪；

3. 是否应撤销前罪缓刑与后罪数罪并罚，如何达到与同案主犯的量刑均衡。

【法院裁判要旨】

广东省佛山市顺德区人民法院经审理认为：何某在介绍陈某给梁某伊始，各方并未就虚开增值税专用发票的数额达成合意，在何某缓刑考验期内虚开发票金额尚未达到构成新罪的犯罪数额，故不宜认定何某在缓刑考验期内犯新罪并据此撤销前罪缓刑。何某在共同犯罪中是从犯，且有自首情节，依法予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百零五条、第二十七条、第六十七条第一款的规定，以虚开增值税专用发票罪判处何某有期徒刑六个月。

一审宣判后，广东省佛山市顺德区人民法院提出抗诉。

广东省佛山市中级人民法院经审理认为：何某在明知梁某有虚开增值税专用发票需求的情况下，介绍其与陈某结识，后陈某、何某对虚开增值税专用发票事宜达成合意，并开始实施虚开行为。虽然在何某的缓刑考验期内虚开的增值税专用发票数额未达追诉标准，但陈某等人后续持续实施的虚开行为未超出缓刑考验期内事前通谋的范围，且犯罪行为未被有效间断，属于基于同一或概括的犯意，连续实施性质相同的数个虚开增值税专用发票行为，系连续犯，应整体评价为一罪。因此，何某在缓刑考验期内已经共谋并着手实施本案虚开增值税专用发票犯罪，何某的行为属于在缓刑考验期内犯新罪，依法应当撤销缓刑，且有再犯危险，依法不符合继续适用缓刑的条件。鉴于何某本案所犯虚开增值税专用发票罪情节轻微，且某供应链公司已向税务部门上缴违法所得并全额缴纳罚款，某供应链公司及陈某均被决定不起诉，故对何某依法可免于刑事处罚。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第二项，《中华人民共和国刑法》第二十七条、第三十七条、第四十七条、第六十七条第一款、第六十九条、第七十七条第一款、第二百零五条、第二十五条第一款的规定，判决：

一、维持广东省佛山市顺德区人民法院(2023)粤0606刑初29号刑事判决的定罪部分；

二、撤销广东省佛山市顺德区人民法院(2023)粤0606刑初29号刑事判

决的量刑部分；

三、被告人何某犯虚开增值税专用发票罪，免予刑事处罚；撤销湖北省大冶市人民法院(2015)鄂大冶刑初字第00561号刑事判决书对被告人何某犯虚开增值税专用发票罪判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币10万元的缓刑部分，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币10万元。

(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除因前罪先行羁押的57日，即自2023年3月23日起至2026年1月24日止。罚金已缴纳。)

【法官后语】

本案争议的焦点在于跨越缓刑考验期的连续犯罪应否整体评价；对于在缓刑考验期内虚开增值税专用发票金额尚未达到犯罪数额标准，能否认定在缓刑考验期内犯新罪；在同案主犯均被不起诉的情况下，本案应否撤销缓刑与后罪数罪并罚，如何达到同案量刑均衡？本案中，何某在明知梁某有虚开增值税专用发票需求的情况下，介绍其与陈某结识，双方达成合意并开始实施虚开行为，各方在商议之初并未就虚开增值税专用发票的限额进行约定，也就是说虚开多少均未超出共谋的概括故意，具体犯罪金额应当以实际虚开的金额为准。在何某的缓刑考验期前后持续实施的虚开行为未超出缓刑考验期内事前通谋的范围，且犯罪行为未被有效间断，属于基于同一或概括的犯意，连续实施性质相同的数个虚开增值税专用发票行为，系连续犯，应进行整体评价。虽然在何某的缓刑考验期内虚开的2份增值税专用发票数额未达追诉标准，但前后虚开的14份增值税专用发票数额已达追诉标准，何某在缓刑考验期内已经共谋并着手实施本案虚开增值税专用发票犯罪，其行为应当认定为在缓刑考验期内犯新罪。根据《中华人民共和国刑法

》第七十七条第一款的规定：“被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。”据此，应当对何某撤

销缓刑，把前罪与后罪所判处的刑罚数罪并罚。本案中，由于某供应链公司已向税务部门上缴违法所得并全额缴纳罚款，公诉机关对某供应链公司及陈某均作出不起诉决定，何某作为本案从犯，如果被判处刑罚会导致同案处置不均衡。鉴于何某本案所犯虚开增值税专用发票罪情节轻微，合议庭根据《中华人民共和国刑法》第三十七条的规定，对何某新犯的虚开增值税专用发票罪免于刑事处罚，并根据《中华人民共和国刑法》第六十九条、第七十七条第一款的规定，撤销前罪缓刑部分，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币10万元。虽然何某最终被决定执行的刑罚貌似比主犯处罚重，但实际上就本案共同犯罪的处罚来说并不存在失衡的问题，何某最终被决定执行的刑罚实际上是前罪因被撤销缓刑应执行的刑期，是对其在缓刑考验期内犯新罪的处罚后果，改判的结果也是考虑到整体量刑均衡的情况。在审理本案中，既要考虑到连续犯的认定原则，又要准确运用法律规定，还要考虑同案处理结果的均衡，不能简单机械地割裂开来认定犯罪数额，仅就新罪进行处罚。

编写人：广东省佛山市中级人民法院 张华伟

行为人“拒不认罪”的情况下，能否适用缓刑

—— 和某某虚开发票案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

南宁铁路运输中级法院(2023)桂71刑终2号刑事裁定书

2. 案由：虚开发票罪

【基本案情】

自2014年至2016年，和某某应某铁路局某工务段材料科梁某某(已判刑)的要求，在双方无实际业务往来的情况下，和某某通过其实际控制的12家建材经营部先后向某铁路局某工务段虚开发票共149张，累计金额815.48143万元。和某某收到某铁路局某工务段转来的“货款”后，按事先约定扣除约9%的税款和手续费，将剩余资金转回至梁某某提供的银行账户。

【案件焦点】

1. 和某某的行为是否构成虚开发票罪；2. 和某某“拒不认罪”能否适用缓刑。

【法院裁判要旨】

南宁铁路运输法院经审理认为：被告人和某某违反国家发票管理制度，在没有任何真实交易关系的情况下，凭空填开发票，情节特别严重，已构成虚开发票罪。被告人和某某主动向公安机关投案，如实供述，是自首，依法可以减轻处罚。同时，和某某供述某铁路局某工务段梁某某的相关犯罪事实属于如实供述自己罪行的要求，不构成立功。发票是会计核算的原始凭证亦是税务稽查的重要依据，虚开发票的行为不仅严重影响会计核算的真实性，而且使不法经营者多列成本，减少所得税等税种的应纳税额，达到偷逃税款的目的，与此同时还存在不法分子利用虚开发票行为达到侵占单位资金、挪用公款、套取国家预算资金等不法目的。本案中，被告人和某某虚开发票为梁某某挪用某铁路局某工务段的公款提供了便利，具有严重的社会危害性，被告人和某某提出不具有社会危害性的观点于法不符，不予采纳。被告人和某某有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。依照《中华人民共和国刑法》第二百零五条之一第一款、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条第二款和第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：

被告人和某某犯虚开发票罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币8万元(缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金在判决生效之

日起十日内一次缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳)。追缴违法所得人民币163096.29元，上缴国库。

一审宣判后，和某某提出上诉。

南宁铁路运输中级法院经审理认为：和某某违反国家发票管理制度，在未发生真实交易关系的情况下，虚开发票金额达815.48143万元，情节特别严重，其行为已构成虚开发票罪。和某某在一审、二审中均辩称涉案工程实际存在，开票行为属如实代开，不应以虚开发票罪论处的意见。经审查，和某某在开票时与某铁路局某工务段之间尚没有实际发生经营业务，和某某并未按照每一份购销合同所对应的数量实际供应材料，发票中所列交易金额、经营种类、交易时间均系虚构，且和某某在收到某铁路局某工务段转来的“货款”后，按事先约定扣除约9%的税款和手续费，将剩余资金又转回至梁某某提供的银行账户，即虚开发票行为已经完成，该行为已经破坏国家发票管理秩序，而购销合同中涉诉工程项目是否真实存在与虚开发票罪的犯罪构成要件之间没有必然联系。故，对其辩解意见不予采纳。鉴于“上诉不加刑”原则，根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第四百零一条第一款第四项的规定，不宜在二审程序中直接撤销缓刑。和某某主动向公安机关投案，如实供述了主要涉案事实，虽提出了相关辩解意见，应属于其对行为性质认识不足，不影响自首成立，一审判决认定和某某具有自首情节，依法应予以确认。和某某在归案后向公安机关交代包括梁某某的相关犯罪事实属于如实供述自己罪行的范畴，不具有立功情节。综上，一审判决认定的主要犯罪事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，审判程序合法，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项的规定，裁定如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

行为人“拒不认罪”的情况下，能否适用缓刑？根据《中华人民共和国刑法》第七十二条第一款的规定，对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的

